

0003794-05.2020.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... referentes à contabilidade do tráfico, circunstâncias estas que evidenciariam que o tráfico não seria exercido pontualmente. Deste modo, é de rigor, pela ausência de provas, a absolvição dos acusados, no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0003794-05.2020.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1427/2020 - Delegacia de Polícia de Tatuí

Réu:

HUGO FERREIRA LOPES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP e Art. 35

"caput" do(a) SISNAD c/c Art. 69 "caput" do(a) CP (Denúncia)

Data da Audiência:

09/08/2022

Em 09 de agosto de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.<sup>a</sup> MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM<sup>a</sup> Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM<sup>a</sup> Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu ALEXSANDRO DE OLIVEIRA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Leandro Eduardo Nunes OAB 196049/SP. AUSENTE o réu HUGO FERREIRA LOPES, não localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certificado às fls. 213, presente seu Defensor, DR. Everton Vidal OAB 283351/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas João Batista de Almeida (GCM) e Daniel Adriano Vieira (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado Alexsandro se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu presente. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM<sup>a</sup> Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de

videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus ALEXSANDRO DE OLIVEIRA e HUGO FERREIRA LOPES, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados criminalmente como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, eis que: 1) no dia 11 de julho de 2020, nesta cidade e Comarca de Tatuí, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 11 de julho de 2020, por volta das 22h05, na Rua Osvaldo Oliveira da Porciúncula - Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustadas, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 5 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 5 gramas, 2 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2 gramas, e 11 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, permaneciam no local da abordagem, que elegeram como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, ALEXSANDRO e HUGO faziam uso de uma área verde existente nas proximidades, onde guardavam e mantinham drogas em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. Os denunciados dividiam as tarefas na empreitada criminosa, sendo que ALEXSANDRO "cuidava" das drogas que estavam escondidas na área verde, enquanto HUGO atendia os usuários e passava o "pedido" para o comparsa que, por sua vez, pegava os entorpecentes na área verde conforme a demanda e entregava as porções para HUGO promover a venda efetiva. Guardas Civis Municipais estavam em serviço no Jardim Europa quando receberam informação de um popular dando conta de que os acusados estavam vendendo drogas no local dos fatos, fornecendo as características físicas e das roupas que eles estavam vestindo (ALEXSANDRO vestindo uma camisa do Corinthians e HUGO com um moleton listrado). Segundo ele, os réus escondiam o entorpecente numa área verde existente nas proximidades, sendo que ALEXANDRO era o responsável por guardar as drogas e, conforme a demanda, entregá-las para HUGO, que permanecia na via pública vendendo as porções para os usuários que ali compareciam. De imediato, os Guardas se dirigiram para o endereço fornecido e, lá chegando, avistaram os denunciados e deliberaram pela abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, HUGO tentou se evadir, porém, não logrou êxito e ambos os denunciados foram de pronto abordados e detidos pelos Guardas Civis. Assim é que, em revista pessoal, os Guardas encontraram 5 porções de cocaína ("aricanduva") em poder de HUGO, além da importância de R\$ 228,75 em espécie, dinheiro angariado com a venda de drogas que os acusados promoviam no local, de forma associada. Com ALEXSANDRO, os Guardas Municipais localizaram 2 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para a venda. Dando continuidade às diligências, efetuando buscas na área verde noticiada, os Guardas Civis lograram encontrar mais 11 porções de cocaína idênticas àquelas anteriormente localizadas, em embalagens individuais e dispostas de modo a facilitar a mercancia, drogas que pertenciam aos acusados e estavam destinadas à venda. Notificados (fls. 118 e 182), os réus apresentaram Defesas Preliminares (fls. 132/138 e 187/190), procedendo-se, então, o regularmente recebimento da denúncia em 15 de março de 2021 (fls. 241/246). Durante a instrução, os réus foram interrogados, bem como foram ouvidas duas testemunhas, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos réus nos termos da exordial. Por outro lado, as Defesas Técnicas dos réus pugnaram pela total absolvição dos acusados, sustentando falta de provas, bem como, subsidiariamente, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a

incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 224/226 e 227/235, bem como certidões a fls. 236/245. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório merece ser julgado parcialmente procedente. Vejamos: É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)" (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Neste mesmo sentido, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)" (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que eles pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse mapeado com precisão as divisões de incumbências da suposta associação criminosa, bem como não foi apreendida grande quantidade de entorpecentes ou anotações referentes à contabilidade do tráfico, circunstâncias estas que evidenciariam que o tráfico não seria exercido pontualmente. Deste modo, é de rigor, pela ausência de provas, a absolvição dos acusados, no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. No

mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/16), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 246/248) e pelas demais provas acostadas nos autos. A autoria é igualmente evidente e clara, a despeito dos acusados terem negado peremptoriamente a prática dos fatos. Senão vejamos: O réu ALEXSANDRO, em solo policial (fls. 09), manteve-se silente. Em juízo, o réu disse que é morador do bairro, que foi buscar duas porções para usar e a polícia lhe enquadrou. Não pode falar de quem foi comprar a droga. Já conhecia os guardas civis e nada tem contra eles e não sabe se eles tem algo contra ele. Estava com um casaco

do Corinthians. Não conhece Hugo e não estavam próximos. A única coisa que fez foi pegar duas porções para usar. Ficou parado, não conseguiu correr. A pessoa que foi comprar a droga pegou-a na área verde. Tem 25 anos. Trabalha como ceramista. Tem dois filhos. Nunca foi processado. De outro lado, o acusado HUGO, em solo policial (fls. 10), manteve-se silente. Em juízo, o réu disse que estava de passagem pelo local e foi abordado. Estava na casa de um amigo e estava perdido no bairro. Não conhece Aleksandro. A única coisa que foi pega com ele foi o dinheiro, pois trabalha numa firma em Tatuí e mostrou o comprovante do saque do dinheiro e eles não quiseram nem saber. Não foi pego droga nenhuma com ele. Não conhecia esses guardas. Não sabe dizer porque forjaram a droga para ele. Quanto a denuncia, a rua estava cheia, só foi lá porque achou que a festa era naquela rua. Trabalha de pedreiro, com carteira assinada. É casado e tem filhos. Já foi processado quando era menor. Tem 27 anos. Verifica-se que os réus ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa negaram os crimes que lhe foram imputados. Entretanto a negativa dos réus restou isolada e desamparada de qualquer lastro probatório. Alexandro afirmou o porte de drogas para uso próprio, ocorre que há elementos outros a evidenciar que auxiliava o corréu Hugo no comercio ilícito. Há Hugo admitiu tão somente a propriedade do dinheiro, não sabendo esclarecer porque os agentes de segurança teriam lhe forjado as 5 porções de cocaína. Por sua vez, o Guarda Civil Municipal Daniel Adriano Veira, em sede policial (fls. 06/07), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento de ROMU e CANIL pelo bairro Jd. Europa, quando foram abordados por um transeunte morador da rua Osvaldo Oliveira da Porciuncula, o qual delatou para a guarnição que por esta rua lá estariam dois sujeitos comercializando droga, o que foi presenciado diversas vezes pelo denunciante. Inclusive, o delator precisou as vestimentas dos traficantes, descrevendo que o indivíduo de cor escura estaria de agasalho do Corinthians e o de cor branca estaria de camiseta listrada de frio (moleton). O denunciante também relatou que o sujeito de cor escura entrava em uma área verde e entregava o entorpecente para o indivíduo de cor branca, o qual, por sua vez, entregava para os consumidores e recebia algo em troca. Deslocaram para o local e, chegando em frente ao número 156, depararam com os dois sujeitos, o quais, ao perceberem que iriam ser abordados, o de cor branca de nome HUGO tentou se evadir, mas ambos abordados. Em revista pessoal, com HUGO, localizou 5 papелotes de cocaína tipo Aricanduva e a importância de R\$ 228,75 em dinheiro. O GCM Almeida localizou com ALEXSANDRO 2 papелotes de cocaína idênticas as que estavam com HUGO. Os indivíduos ficaram na custódia dos GCMs Almeida e Vanessa, enquanto entrou na área verde, descrita na denúncia. Naquele lugar, localizou mais 11 papелotes de cocaína idênticas as outras localizadas. Em juízo, a testemunha disse que a equipe estava em patrulhamento pelo Jardim Europra quando receberam a denuncia de um morador de que dois indivíduos estariam fazendo o trafico, um deles era de dor escuro e trajava camiseta do corinthias e se deslocava até uma área verde para pegar as drogas e outro rapaz era branco e trajava um moleton. Avistaram os réus, eles apresentaram atitude suspeita e com Hugo foram encontradas 5 porções de cocaína e dinheiro.. Com Aleksandro foram encontradas duas porções. Nessa área verde foram localizadas mais 11 porções de cocaína idênticas as que estavam com os réus. Os réus negaram os fatos. O morador disse ainda que não aguentava mais essa conduta dos réus de vender drogas. Disse que Aleksandro, vulto Pelé era morador do bairro, mas que Hugo não era morador do bairro, estava ali para fazer a venda. O Aleksandro é bastante conhecido. Perguntas da defesa - abordou o Hugo. Avistou o Hugo e eles estavam próximos um do outro. Não sabe dizer a metragem certa da distancia da área verde, mas são poucos metros, eles não deixam a droga muito distante, pois tem medo de alguém pegar a droga. Os réus ficaram calados. Só os réus estavam no local. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal João Batista de Almeida, em sede policial (fls. 08), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, a testemunha disse que no dia dos fatos a equipe de Romu e Canil estava em patrulhamento quando foram abordados por um morador da rua Osvaldo de Oliveira Porciuncula, dizendo estar cansado do trafico no local, relatou dois indivíduos, um de cor escura com jaqueta do Corinthians e o de cor clara com uma blusa de moleton. O de cor escura pegava a droga numa área e entregava para o

de cor clara vender. Foram ao local apontando, identificaram os indivíduos. Hugo tentou se evadir, mas foi abordado e com ele encontrado 5 porções de cocaína e R\$220,00. Com Alexsandro estava duas porções de cocaína. O GCM Adriano deslocou-se até área verde, próxima ao local e ali encontrou 11 porções de cocaína idênticas as que estavam com o réu. O morador disse que há uma semana os réus estavam ali. Conhecia Alexsandro dos meios policiais. As porções eram todas idênticas. No local há bastante consumidores. No momento da abordagem havia mais pessoas, mas apenas os réus correspondiam às características. Nunca havia abordado o réu Alexsandro, mas seu nome é mencionado em denúncias. Ele é morador do bairro, já Hugo mora no outro bairro. Os réus eram as pessoas mais próximas da área verde. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente os réus ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas, parte com os réus, e outra parcela próximo deles, onde os acusados guardavam as drogas; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 246/248), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas porções, própria da venda a varejo; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a exata correspondência, inclusive de características físicas e vestimentas, bem como área geográfica de atuação, dos réus com os traficantes delatados anonimamente; e 5) o comportamento suspeito dos acusados, manifestado quando notaram que seriam abordados.

Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o

local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 246/248) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo e transportar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser-lhe imposta. I – DO RÉU HUGO: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, observo que o acusado ostenta condenação definitiva por fatos anteriores, mas cujo o trânsito em julgado se operou no curso da presente ação penal (fls.

238/239), o que também é elemento caracterizador de inclinação criminosa e maus antecedentes, a despeito de não configurar reincidência. Nesse sentido: “a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.” (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013).. Por tal razão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é de rigor, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é múltipla (fls. 240/241 e 244/245), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, a qual torno definitiva pela ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Consigno que a reincidência do réu e seus péssimos antecedentes impedem a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a reincidência do acusado e seus maus antecedentes. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis ou dos benefícios previstos no art. 44 do CP. II – DO RÉU ALEXSANDRO: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Isso porque, a despeito de contar com condenação criminal definitiva (fls. 236/237), tem-se que essa se refere a fato posterior ao que se julga in casu. E, portanto, não pode ser valorado negativamente na primeira fase de dosimetria da pena. Nesse sentido: “Impossibilitada a aplicação de antecedentes criminais relativos a infrações praticadas após àquela objeto da denúncia. Precedentes” (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013). Assim, fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública pelas mesmas razões acima expostas. Ademais, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito e que, inclusive, também foi condenado pelo exercício da traficância (fls. 236/237), resta evidenciada sua dedicação a atividades criminosas e, conseqüentemente, inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “É possível a

utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades

criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c.c. o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando sua personalidade delitiva. Ademais, observo que as circunstâncias que justificaram a fixação do regime prisional mais severo também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. III – DAS DISPOSIÇÕES COMUNS: Por derradeiro, quanto a ambos os acusados, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). IV – DO DISPOSITIVO E CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu ALEXSANDRO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; 2) condenar o réu HUGO FERREIRA LOPES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 3) absolver os réus da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o Apelo em Liberdade, na medida em que permanecem inalteradas as razões que possibilitaram aos réus responderem a esse feito soltos (fls. 58). Deve ser observado, contudo, que o réu ALEXSANDRO acha-se preso por outro feito. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foram assistidos nos autos por defensor dativo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intímem-se os réus para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 228,75 em dinheiro – fls. 78) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei". Pelos Defensores dos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo os recursos interpostos, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competentes certidões de honorários (fls. 120 e 183). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13



do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado,  
Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA